

刑法
No.314

H20-18

(配点：3)

月 日

月 日

横領罪（刑法第252条第1項）に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲が、乙から賃借している同人所有の骨董品について、その売却代金を自己の借金の返済に充てるつもりで乙に無断で丙にその買取りを求めた場合、甲の行為は不法領得の意思が外部的に発現したといえるから、丙が買受けの意思表示をしなくても甲には横領罪が成立する。
- イ. 甲が、自己が所有し、登記簿上も自己が所有者となっている土地を乙に売却し、その売買代金の受領を終え、当該土地の所有権が乙に移転した後、乙がその移転登記を完了する前に、甲が、事情を知った丙に当該土地を売却し、丙がその移転登記を完了した場合には、丙が当該土地の所有権の取得を乙に対抗できるか否かにかかわらず、甲には横領罪が成立する。
- ウ. 甲は、19歳の乙と同人所有の絵画の売買契約を締結し当該絵画の引渡しを受けたが、乙が親権者の同意がないことを理由に同契約を取り消した。甲はこれを知りながら、乙に無断で当該絵画を丙に売却して丙に引き渡した場合、甲乙間の売買契約が初めから無効であったものとみなされるため、甲と乙の間に委託信任関係は存在しないこととなるから、甲には横領罪は成立しない。
- エ. 甲が、不在中の自宅に誤って配達された他人あての贈答品の高級食材を食べてしまった場合、甲の当該食材に対する占有は委託信任関係に基づくものではないので、甲には横領罪は成立しない。
- オ. 甲が、自己が所有し、登記簿上も自己が所有者となっている土地を乙に売却し、その売買代金の受領を終え、当該土地の所有権が乙に移転した後、乙がその移転登記を完了する前に、甲が、当該土地に自己を債務者とし丙を抵当権者とする抵当権を設定し、その設定登記を完了したとしても、抵当権が実行されない限り当該土地に関する乙の所有権は影響を受けないから、甲には横領罪は成立しない。

1. ア イ オ
2. ア ウ
3. イ ウ エ
4. イ エ オ
5. ウ オ

No314

横領罪の成否

正答率

H20-18

正解

5

74%

ア 正しい

大判大2.6.12は、横領罪（252条1項）は、自己の占有する他人の財物に対して、不法領得の意思の発現行為があることによって成立し、第三者の行為が介在することを要しないとした上で、自己の占有する他人の財物を不法に第三者に売渡そうとする行為があれば、相手方の買受けの意思表示を待たず、横領罪は完成するとしている。よって、甲の行為は「横領」にあたり、甲には横領罪が成立する。

イ 正しい

横領罪における「占有」は、濫用のおそれゆえに、事実上の占有のほか、法律上の占有も含むと解されているから（大判明44.2.3、大判大4.4.9、最判昭30.12.26）、乙に土地を売却しても、甲に登記名義が残されている本件では、甲に土地に対する「占有」が認められる。横領罪の「他人の物」に該当するためには、刑法上の当罰性の観点から、売買契約であれば、売買契約締結の意思表示のほか、代金の支払を要すると解されているが、甲が乙から代金を受領しているから、土地は、「他人の物」にあたる。そして、占有者が自己の占有する他人の財物を第三者に売却する行為は、不法領得の意思の発現行為たる「横領」にあたるから（最大判昭24.6.29）、甲の行為には横領罪が成立する。

ウ 誤っている

委託・寄託関係は、委任・寄託契約に限らず、契約の履行に関係して自己が相手方のために占有していれば足り、取消しや解除により無効に帰した契約に基づく占有は、当事者は原状回復義務を負うことから、委託・寄託関係に基づく占有であるとされる。裁判例は、売買契約が合意解除された後の占有者の抵当権設定行為につき、横領罪の成立を肯定している（札幌高判昭30.11.17）。よって、本記述では乙の取消しにより、甲は乙に原状回復義務を負うことから、甲の占有は委託・寄託関係に基づくものといえ、丙への売却行為につき横領罪が成立する。

エ 正しい

大判大6.10.15は、誤配達された郵便物の占有は委託・寄託関係に基づかないとしている。よって、自宅に誤って配達された他人宛の贈答品に対する甲の占有は委託・寄託関係に基づくものとはいえない。そのため甲がそれを食べたとしても、横領罪は成立せず、遺失物横領罪が成立するととどまる。

オ 誤っている

甲は、自己所有の土地を乙に売却し、代金も受領しているから、土地は「他人の物」にあたり、土地の登記名義は甲に残っているから、甲は土地を「占有」しているといえる。そして、自己の債務を担保するため、土地に第三者のために抵当権を設定し、設定登記を完了した行為は、不法領得の意思の発現行為である「横領」行為にあたるから、甲は当該土地を「横領」したといえる。よって、甲には横領罪が成立する。